Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões

Rua Hildebrando Westphalen, 553 - Bairro: Centro - CEP: 98300000 - Fone: (55)3029-9969 - Balcão Virtual: 55996178488 - Email: frpalmiss1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000817-25.2021.8.21.0020/RS

AUTOR: ALFRINO DE OLIVEIRA FERREIRA

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ALFRINO DE OLIVEIRA FERREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, sustentando, em síntese, ser portadora da doença diagnosticada pelo CID 10 C 61 - câncer maligno de próstata. Asseverou que necessita fazer o uso contínuo do medicamento abiraterona 250mg, sendo que não possui condições financeiras de arcar com o custo. De forma que, este é indispensável em razão da enfermidade que lhe acomete. No mais, fez considerações acerca do dever do Estado em fornecer medicamentos. Postulou a procedência da ação para condenar o réu a fornecer o medicamento pleiteado. Juntou documentos.

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação, arguindo a necessidade de observância da denominação comum brasileira. Sustentou a necessidade de cumprimento dos critérios fixados pelo STJ no TEMA nº 106, o que não foi atendido no caso concreto. Argumentou acerca da necessidade de atendimento ao TEMA 793 STF, sendo determinada a inclusão da União no polo passivo da ação. Ao final, postulou a improcedência da demanda (evento 18).

Houve réplica (evento 21).

Solicitada Nota Técnica do NatJus (evento 30).

Sobreveio aos autos (evento 46).

Quanto a produção de provas, ambos reportaram-se por não possuir mais nada a produzir.

Intimado o Ministério Público, manifestou-se pela procedência da ação (evento 127).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relato.

Passo a decidir.

O feito está apto para julgamento, foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal. Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

Mérito.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa seara, diante de omissões do Poder Executivo, a fim de concretizar o acesso das pessoas aos medicamentos, exames ou tratamentos de que necessitem acaso não tenham condições para adquirir. É o que decorre da análise conjunta dos dispositivos legais atinentes à matéria.

Com efeito, dispõe o artigo 196 da Constituição Federal (CF) – de eficácia imediata e concreta – que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

E o artigo 23, inciso II, da CF/88, preceitua:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

A Constituição Estadual, por sua vez, em seu artigo 241, ao tratar da matéria, dispõe:

Art. 241. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.

Outro não é o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.080/1990, que disciplina as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ainda a Lei Estadual 9.908/1993:

Art. 1º - O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Parágrafo único - Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente.

Evidente, portanto, que o direito à saúde foi priorizado tanto pelo legislador constituinte, quanto pelo legislador infraconstitucional. Erigir tal direito a tão alta conta deve-se ao fato de que se encontra diretamente conectado com o direito fundamental à vida, bem como ao princípio norteador da dignidade do ser humano.

Não se pode olvidar que vivemos em um Estado Social Democrático, que, por exigir de seus cidadãos uma grande contribuição por meio dos tributos, tem o dever de assegurar a devida contraprestação, concretizando uma gama de direitos, precipuamente aqueles elencados no art. 6º da CF, dentre os quais se encontra a saúde.

Ressalte-se que, no que se refere ao direito a saúde, o próprio legislador constituinte vinculou um patamar mínimo da receita dos entes federados para atender tal demanda (art. 198, § 2º da CF). De modo que, ao menos em princípio, as limitações orçamentárias do Estado não podem se constituir em óbice para a implementação do referido direito.

Portanto, têm os entes públicos o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico àqueles que necessitem de tal prestação para própria subsistência, não tendo condições de buscá-la se não junto ao Estado.

A concretização do direito à saúde incumbe a todos os entes federados, com atuação integrada do poder público, como um todo, isto é, União, Estados e Municípios e Distrito Federal.

Saliente-se que a obrigação de concretizar o direito à saúde caracteriza-se como solidária. Destarte, as repartições internas de competência entre os entes federados concernentes ao gerenciamento do Sistema Único de Saúde não se constituem em óbice para que o cidadão tenha atendida a prestação a qual faz jus.

Outrossim, diante da omissão estatal (Poder Executivo) na concretização do direito à saúde, cabível a intervenção do Poder Judiciário, a fim de dar efetiva concreção aos direitos fundamentais.

Essa intervenção (tutela judicial) nada mais faz do que concretizar a aplicação do postulado da proporcionalidade, na sua vertente de proibição da insuficiência, segundo o qual, quando um direito fundamental não está sendo suficientemente protegido pelo Poder Público, tem o Poder Judiciário o dever-poder de determinar que a prestação fática (consulta, cirurgia, medicamento e insumos) seja prestada à parte.

Nessa linha, a jurisprudência já consolidada dos nossos Tribunais. No âmbito do STF:

*PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - **O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.** Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.*

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524) (grifei)

*AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. **A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.***

(AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifei).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1.315.346/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013).
(...)
(AgRg no REsp 1553088/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015)

Por fim, na mesma toada, a posição do TJ-RS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ESTADO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. A ausência de inclusão de medicamentos em listas prévias não é obstáculo ao seu fornecimento por qualquer dos entes federados. É direito de todos e dever do Estado (Poder Público) promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, quando o cidadão não possuir meios próprios para adquiri-los. 2. O atestado médico do profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora, bem como a adequação da medicação solicitada para a doença que a acomete. 3. Não se pode cogitar, em nome de uma eventual economia de dinheiro pelo ente público, da possibilidade de substituição do medicamento indicado pelo médico da parte autora, por outros similares, correndo o risco de tornar inócuo o tratamento ou prejudicar a saúde de cidadão. 4. Cabível a determinação de apresentação periódica de laudo médico para avaliação da pertinência na continuidade do tratamento, inclusive evitando-se gastos desnecessários de verbas públicas. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70067567891, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 15/01/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. - A responsabilidade solidária entre a União, os Estados-Membros e os Municípios pelo fornecimento gratuito de tratamento a doentes necessitados decorre de texto constitucional (CF, art. 23, inciso II e art. 196). - Aos entes da Federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (artigos 6º e 196 da Constituição Federal). - Afastada a alegação de que necessária a inclusão dos medicamentos em lista previamente elaborada pelo Ministério da Saúde como sendo de responsabilidade exclusiva de cada ente da Federação, para fins de cumprimento do dever constitucional. - Rejeitada a tese de possibilidade de substituição dos medicamentos pelas alternativas existentes no Sistema Único de Saúde. A prescrição do médico assistente da parte autora é que melhor atende os pressupostos de adequação e necessidade da medicação. - Fornecimento do medicamento de acordo com a nomenclatura utilizada na Denominação Comum Brasileira, com fulcro na Lei nº 9.787/99, a fim de aquisição dos fármacos a um custo menor pelo ente público. - Verba honorária fixada de acordo com o princípio da moderação. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA, APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70066715269, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 15/01/2016)

No caso, a parte autora demonstrou que não possui condições de adquirir os medicamentos sem prejuízo de seu próprio sustento, tendo em vista tratar-se de hipossuficiente econômico. E, diga-se, não há provas no sentido contrário (demandante com condições financeiras). Ademais a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, a qual já faz uma triagem no público que realmente necessita do atendimento. Portanto, nada mais há que se discutir sobre as condições financeiras da demandante.

Afasto, ainda, qualquer alegação de violação à igualdade. Em linhas gerais, o mencionado princípio determina que duas pessoas sejam iguais ou diferentes, segundo um mesmo critério de comparação, para uma mesma finalidade. Ora, o atendimento específico do pedido da parte nada mais faz do que restaurar a normatividade do direito fundamental e, portanto, de igualar pessoas naquilo que a Constituição manda ser comum a todas. Logo, outorga-se a cada postulante a igualdade material prevista na Lei Fundamental, pois o que as desiguala é justamente a omissão do Poder Público.

Demonstrada, assim, a responsabilidade do demandado na dispensação dos fármacos postulados pela parte autora.

No caso em tela, há que se observar que a parte autora apresentou atestado médico informando a necessidade de utilização do fármaco abiraterona 250mg.

No laudo médico do evento 44, LAUDO1, o médico informou sobre o quadro clínico do autor. Ressaltou que o ACETATO DE ABIRATERONA apresenta ação comprovada para essa neoplasia e que não pode ser substituído por similares.

Ainda, a nota técnica do E-NatJus concluiu:

Conclusão

Tecnologia: ACETATO DE ABIRATERONA

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA

Página 3 de 4

METASTÁTICO, conforme dados médicos acostados ao processo.

CONSIDERANDO que há evidência em literatura médico-científica que a terapia com ABIRATERONA traz benefícios a pacientes em situações análogas à acima mencionada, e que a precocidade do tratamento determina melhor prognóstico.

CONSIDERANDO o parecer favorável do CONITEC à incorporação da ABIRATERONA ao SUS na situação acima descrita.

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS técnicos para sustentar a indicação da ABIRATERONA no caso em análise na presente solicitação, em regime de urgência.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Isso posto, diante das alegações da parte autora, corroborada pela documentação juntada aos autos, restou evidente a necessidade de receber o tratamento com o fármaco indicado, na quantidade e no prazo determinado na inicial.

Quanto ao argumento do tratamento oncológico no âmbito do Sistema Único de Saúde ser atribuído aos CACONs/UNACONs, denota-se, pela documentação médica acostada aos autos, que o autor realiza seu tratamento junto ao Hospital de Caridade de Ijuí/RS, nosocômio cadastrado como CACON.

Na forma do art. 3º da Lei nº 9.787/1999, resta autorizado o demandado a fornecer a medicação segundo a denominação comum brasileira (DCB).

Diante do exposto, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **ALFRINO DE OLIVEIRA FERREIRA** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** para, confirmando os efeitos da tutela antecipada, **CONDENAR,** de forma definitiva, o ente público ao fornecimento do medicamento referido na petição inicial, na forma e com as especificações de que o autor necessita.

Cabível a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor recebido deverá ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP.

Ainda, como o objeto da ação é o direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, tem-se que a fixação por critério de equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC, mostra-se mais adequada, fixando o valor de R$ 900,00.

Não é caso de remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, e da Súmula 490 do STJ, já que a condenação não é superior a 100 (cem) salários-mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **DAVI DE SOUSA LOPES, Juiz de Direito**, em 16/4/2024, às 14:6:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10058516622v2** e o código CRC **159f9840**.